

1500754-83.2021.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO
Comarca: Igarapava
Foro: Foro de Igarapava
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE OCORRIDO NO INTERIOR DE UM BAR. EQUIPARAÇÃO A RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, policiais militares lograram êxito em apreender com o paciente considerável quantidade de substância entorpecente, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500754-83.2021.8.26.0242 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500754-83.2021.8.26.0242

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OBEADIO VIANA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra OBEADIO VIANA, qualificado nos autos (fls. 47), dando-o como incurso nas sanções previstas pelos artigos 12, caput, e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei Federal n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), em concurso formal na forma do artigo 70, do Código Penal, pela suposta prática dos fatos descritos na inicial acusatória (fls. 58/59). A denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2021 (fls. 60/62).

Citado (fls. 67/68), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 83/85).

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), foi determinado o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória (fls. 91/94).

A instrução foi realizada, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como realizado o interrogatório do acusado (fls. 108/112 - mídias digitais).

Na mesma oportunidade, o Ministério Público, em memoriais finais, pugnou pela procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e teceu considerações em cada uma das etapas de dosimetria da pena (fls. 108/112).

Por sua vez, a Defesa requereu a decretação de nulidade do processo em razão do ingresso dos policiais militares no imóvel do acusado, após as 18h00min (dezoito horas), sem mandado judicial, autorização ou suporte legal. Subsidiariamente,

requeriu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 113/117).

Em seguida, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A preliminar de nulidade em razão do ingresso dos policiais militares no imóvel pertencente ao acusado confunde-se com o mérito e como tal será analisado.

Ademais, a relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo a analisar o mérito.

O acusado foi denunciado porque, supostamente, no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 00h10min, na Rua Aluísio Ciro Colmanetti, n. 930, Centro, Aramina, possuía e tinha em depósito arma de fogo, com numeração, marca ou outro sinal de identificação suprimido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu, supostamente, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em seu local de trabalho.

De acordo com os autos, após atendimento de ocorrência relativa a apreensão de arma de fogo no mesmo local, os policiais militares realizaram buscas na barbearia do acusado, constatando a existência de arma de fogo, calibre .38, com numeração suprimida, na cozinha, e, ainda, um revólver calibre .38 com numeração, mas sem os devidos registros, próximo à mesa de bilhar.

Após regular instrução probatória, a pretensão acusatória deve ser acolhida.

A testemunha de acusação Diego Rodrigo de Souza, policial militar ouvido em Juízo, disse que realizava patrulhamento tático em Aramina, a título de reforço, e uma pessoa chegou até os policiais e disse que, na barbearia, havia um rapaz na porta com arma na cintura, razão pela qual ficou preocupada. Declarou que estavam próximos ao local, dirigiram-se para lá e avistaram o indivíduo, que foi abordado sem resistência. Afirmou que, com o rapaz abordado na porta da barbearia, localizaram uma arma .40, arma de uso restrito à época, sendo que, por segurança, decidiram abordar todos que estavam no estabelecimento e fazer a revista pessoal. Contou que, ao questionar se existiam armamentos no local, as pessoas aparentaram nervosismo e não falaram que não tinha, razão pela qual prosseguiram com a revista no estabelecimento comercial e o outro policial localizou um revólver .38, que entregou a ele, ocasião em que notaram que a numeração estava suprimida e havia munições intactas e deflagradas. Disse que colocaram a arma em local seguro e o outro policial prosseguiu as buscas, localizando outro revólver próximo à mesa de bilhar, enfatizando que a numeração estava visível, mas não foi possível localizar o cadastro no SINARM ou Exército e, portanto, sem registro no Brasil. Descreveu que prosseguiram a revista e localizaram algumas munições, ao que o réu não resistiu e disse que tinha algumas munições, razão pela qual foram até sua residência e lá localizaram. Esclareceu que o primeiro abordado se identificou como CAC, que tinha a documentação da .40, bem como tinha uma calibre .12 e munições na residência, razão pela qual realizaram a vistoria e, ante sua legalidade, levaram para a Delegacia para segurança da equipe, sendo liberada em seguida, além de munições de uso restrito. Acrescentou que, na Delegacia de Polícia, foi realizada a apreensão e os dois abordados foram liberados, esclarecendo que a .40 e os dois .38 ficaram apreendidos, enquanto a calibre .12 foi liberada para o proprietário. Esclareceu que a abordagem ocorreu à noite, não se recordando da hora exata. Acrescentou que o réu estava no interior da barbearia, que funcionava no momento e havia 4 pessoas no local (o primeiro abordado com a .40, o dono da barbearia OBEADIO e outros dois rapazes). Disse que, quando entraram no estabelecimento comercial, o proprietário autorizou o ingresso dos policiais, frisando que era um local de acesso público e ingressaram para segurança. Confirmou, ainda, que foram localizadas, pelo PM Pires em sua presença, dentro da barbearia, duas armas de fogo: uma com numeração suprimida e outra sem supressão, além de munições. Declarou que o acusado confirmou a propriedade das armas e disse, informalmente, que gostava do armamento, tinha adquirido e estava vendendo (fls. 108/112 - mídia digital).

No mesmo sentido, seu depoimento em fase policial (fls. 07).

Ainda, o policial militar Marcos Vinícius da Silva Pires, arrolado como testemunha de acusação, declarou, em Juízo, que estavam realizando patrulhamento de apoio em Aramina e chegou denúncia, através de pessoa que pediu anonimato, de que, dentro da "Barbearia do OBEADIO" existiam indivíduos armados, razão pela qual deslocaram-se ao local e abordaram, na porta de entrada, indivíduo de nome Mike, que estava com uma pistola na cintura, mas informou que tinha autorização para porte, existindo, de fato, documentação, mas a forma com que ele portava a pistola era irregular. Disse que, para segurança da equipe, como existiam outros indivíduos dentro da barbearia, realizaram uma busca tanto nos indivíduos, quanto no interior da barbearia. Contou que, na cozinha da barbearia, localizou um revólver .38, com numeração suprimida, e 3 munições intactas e, posteriormente, em uma estante próximo à mesa de bilhar, achou outro revólver calibre .38, que não estava com numeração suprimida e continha 2 munições intactas, frisando que ainda localizaram uma pistola de "air soft", que também foi apresentada no plantão policial. Contou que, no desenrolar da ocorrência, OBEADIO informou que havia munições em sua residência, razão pela qual deslocaram-se até lá, com autorização e na presença dele, e acharam 10 cartuchos deflagrados e 1 munição intacta no quarto. Narrou que, ante o exposto, conduziram OBEADIO e Mike, bem como os objetos apreendidos, ao plantão policial, onde foram ouvidos e liberados. Esclareceu que os fatos ocorreram no período noturno, mas não sabe precisar o horário. Confirmou que Mike, que portava uma pistola, estava na entrada da barbearia, que estava aberta e havia frequentadores no local tomando cerveja. Afirmou que OBEADIO estava no interior da barbearia, frisando que, por se tratar de local público e ante a localização de pistola de forma irregular em pessoa no interior da barbearia, prosseguiram a vistoria. Disse que foi ele quem localizou as armas de fogo e munições, acrescentando que não se recorda o que o réu disse, tendo em vista que ele se comunicou mais com o PM Sargento Diego, comandante de equipe. Questionado pela Defesa, disse que o Sargento Diego falou com o réu OBEADIO, que autorizou o ingresso dos policiais militares no local e afirmou que o próprio declarante enfatizou que, por tratar-se de local público, no caso, uma barbearia, não seria necessária a autorização dele, acrescentando que o acusado autorizou e acompanhou todas as buscas (fls. 108/112 - mídia digital).

No mesmo sentido, foram as suas declarações em fase policial (fls. 06).

Os depoimentos dos policiais militares se revelaram coesos e harmônicos, uma vez que as circunstâncias fáticas foram descritas em detalhes, revelando-se o local e a forma como as armas e munições foram encontradas, o que ficou corroborado pelo auto de exibição e apreensão e laudos acostados aos autos (fls. 08/09 e 26/29, 34/37 e 38/41).

A jurisprudência já pacificada preconiza que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Neste sentido, segundo o E. TJSP: "(...) No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'lato sensu'(...)" (E. TJSP, Apelação Criminal n. 3001516-50.2013.8.26.0292, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ 11.07.2017).

O acusado OBEADIO VIANA, em seu interrogatório judicial, confessou os fatos, confirmou a propriedade das armas de fogo e munições apreendidas e declarou que são herança de seu avô, que residia em Águas Vermelhas, faleceu e deixou as armas para ele. Disse que, no momento dos fatos, o estabelecimento estava funcionando

normalmente, pois atende por agendamento e alguns clientes saem do trabalho mais tarde e tem o costume de esperá-los (fls. 108/112 – mídia digital).

Em sede extrajudicial, confessou os fatos nos mesmos termos (fls. 10).

Como se vê, além dos depoimentos coesos e claros dos policiais militares, o acusado confirmou que a posse das armas de fogo e munições.

Pois bem.

Antes de adentrar na análise da materialidade e autoria dos delitos pelos quais o acusado foi denunciado, é imperioso analisar a questão relativa ao ingresso dos policiais militares no estabelecimento comercial do acusado OBEADIO.

Consigno que, conforme disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Notável, portanto que, o direito à inviolabilidade não é, de todo modo, absoluto e afasta-se no caso de: a) consentimento do morador; b) flagrante delito; c) desastre; d) necessidade de prestar socorro; e) determinação judicial, durante o dia.

De todo modo, desde já registro que os policiais foram uníssomos ao afirmar, em Juízo, que OBEADIO autorizou seu ingresso na barbearia e a realização de buscas no local e, posteriormente, em sua residência, valendo ressaltar, aliás, que vinculados à Polícia Militar de outra Comarca, não existindo nos autos qualquer motivo crível apto a afastar a credibilidade de seus relatos, como já exposto, tampouco a existência de quaisquer motivos para prejudicar o réu (fls. 108/112 – mídias digitais).

Acrescento, ainda, que o acusado, em seu interrogatório judicial, limitou-se a confessar a posse das armas de fogo e munições, discorrendo sobre sua origem e não esboçou qualquer manifestação no sentido de eventual abuso ou ilegalidade na atuação policial, particularmente em relação à eventual recusa em seu ingresso no estabelecimento comercial (fls. 108/112 – mídia digital).

Anoto, de todo modo, que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no RE 1.368.160 RG/RS, decidiu pela repercussão geral do Tema n. 1208, para discutir, “(...) à luz dos artigos 2º; 5º, XI; 18, e 144, §7º, da Constituição Federal, os requisitos de validade do consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio, considerando o disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República e os princípios da inviolabilidade do domicílio, da dignidade da pessoa humana, da vedação à proteção deficiente e da segurança jurídica.”, tendo em vista aparente choque entre sedimentada jurisprudência da Corte Constitucional no sentido de que o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade de diligências (vide HC 191.508-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/11/2020), com entendimento das turmas penais do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual caberia ao Estado demonstrar, de modo inequívoco (inclusive através de registro escrito e gravação audiovisual) do consentimento expresso do morador para entrada da polícia em sua casa, quando não houver mandado judicial (vide Habeas Corpus n. 598.051 e 616.584).

Além desta questão, registro que a apreensão das armas e munições, inicialmente, teriam ocorrido na barbearia do acusado, e, só após, houve deslocamento para a residência de OBEADIO, quando, então, foram encontradas outras munições.

A confirmação de que o endereço da barbearia e o domicílio do acusado encontram-se no próprio boletim de ocorrência acostado aos autos (fls. 03/05), valendo apontar que os fatos ocorreram na Rua Aluísio Ciro Colmanetti, n. 930, Centro, Aramina, enquanto o domicílio do acusado OBEADIO situa-se na Avenida Luiz Basso, n. 241, Natal Abadia, Aramina/SP – informação constante ainda em sua qualificação (fls. 47) e no mandado de citação devidamente cumprido (fls. 67/68).

Ressalto que os policiais foram enfáticos ao afirmar que, apesar do avançado da hora, a barbearia estava aberta e com clientes, fato confirmado pelo próprio réu em seu interrogatório judicial.

Não existem dúvidas de que estabelecimentos comerciais (no caso, barbearia), em funcionamento e abertos ao público, não gozam da mesma proteção constitucional

conferida à casa dos cidadãos, de tal modo que não vislumbro violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Não é outro o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE OCORRIDO NO INTERIOR DE UM BAR. EQUIPARAÇÃO A RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, policiais militares lograram êxito em apreender com o paciente considerável quantidade de substância entorpecente, em condições de fracionamento típicas da mercancia ilícita, além de apetrechos que indicavam o manuseio e preparação da droga, no interior de um bar - embaixo do balcão -, estabelecimento comercial que estava aberto ao público. 2. Desta forma, verifica-se que o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no HC N. 704.252/SP 2021/0353216-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 29/03/2022, p. DJe 04/04/2022). HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL ABERTO AO PÚBLICO. INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. LICITUDE DAS PROVAS. ACESSO ÀS MENSAGENS DE TEXTO TRANSMITIDAS POR TELEFONE CELULAR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias concluíram que as drogas foram encontradas pelos policiais militares no bar do Paciente (dentro de uma bolsa próxima ao balcão), ou seja, em local aparentemente aberto ao público, que não se enquadra no conceito de domicílio, ainda que por extensão. 2. Para acolher a alegação da Defesa de que a droga teria sido encontrada na residência do Acusado, e que "havia cerca de quinze homens em sua lanchonete, pois estavam realizando um 'chá de fralda', já que sua companheira estava grávida", seria necessário, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é impróprio na via do habeas corpus. 3. "O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida" (AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ, HC n. 468.968/PR 2018/0237444-9, Relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07/05/2019, p. DJe 20/05/2019).

De qualquer forma, registro que, conforme relatos dos policiais militares em juízo, bem como descrição dos fatos no comprovante no BOPM n. 202102201201709 (fls. 12/25 - especificamente, fls. 24), também inequívoca a abordagem de Mayk Rezende Correa e localização de arma de fogo em sua posse na porta de entrada da barbearia do réu OBEADIO, justa causa mais do que suficiente para caracterizar estado flagrancial, bem como para autorizar o ingresso no local e averiguação da fundada suspeita da existência de armazenamento de outras armas e munições, o que acabou por se concretizar.

Encontra-se devidamente documentada a abordagem de Mayk Rezende Correa (fls. 15) e apreensão de "QUINZE MUNIÇÕES CAL 44 MAGNUM INTACTAS" (fls. 17), "17 MUNIÇÕES INTACTAS CAL 357 MAGNUM", "46 MUNIÇÕES INTACTAS CALIBRE 40" (fls. 18), "TRES ESTOJOS DEFLAGRADOS CALIBRE 357 MAGNUM", "TRINTA E SEIS MUNIÇÕES INTACTAS CALIBRE 12" (fls. 19), bem como uma pistola Taurus calibre 40, com dois carregadores, número de série AAM121102 (fls. 21), pertencentes a ele.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já apreciou o mencionado dispositivo constitucional, registrado como Tema n. 280 em sede de repercussão geral, no leading case RE 603.616 RG, e fixou a tese de que "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (STF, RE 603.616, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. DJE 10/05/2016). Logo, após localizarem arma de fogo portada por indivíduo na porta de entrada do estabelecimento, mostrar-se-ia temerária a atitude dos policiais militares caso não

tivessem decidido pelo ingresso na barbearia do réu e averiguação da fundada suspeita da existência de armazenamento de outras armas e munições, de modo que, após analisar com atenção o contexto fático inerente aos autos, considero que, de fato, os policiais militares agiram com correção, prudência e em estrito cumprimento do dever legal, tanto que encontraram mais armas e munições. Ademais, não se discute que os crimes em apuração (artigos 12, caput, e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei Federal n. 10.826/03) possuem natureza permanente, de tal sorte que o estado flagrantial se prolonga no tempo, o que justifica o ingresso e excepciona a inviolabilidade domiciliar, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Visando apurar eventuais arestas, é rotineiro o auxílio de policiais militares lotados nas cidades vizinhas, especialmente na sede do batalhão (Franca/SP), tendo em vista o escasso quadro de servidores lotados nas cidades pertencentes à Comarca e a expansão da criminalidade rumo ao interior visando aproveitar-se desta fragilidade, não existindo nos autos nenhum elemento apto a comprovar o uso de força física pelos policiais militares.

Em suma, em que pese o esforço argumentativo da Defesa, não há que se falar em nulidade de provas decorrentes da alegada “invasão ilegal” e, via de consequência, as provas são lícitas, de tal modo que o prosseguimento da presente ação criminal é medida que se impõe.

I) Do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei Federal n. 10.826/03: A materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida foi evidenciada pelo boletim de ocorrência n. 114/2021 (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), pelo B0/PM n. 202102201201709 com fotografias da arma e munições (fls. 12/25), pelo laudo pericial (fls. 26/29), pelo relatório final (fls. 50/51), pelos elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, bem como pela prova oral colhida em juízo.

De igual modo, a autoria também foi demonstrada.

Inexiste discussão acerca do fato de que a arma de fogo foi apreendida na barbearia do réu.

Além da confissão do réu, os depoimentos dos policiais foram uníssonos e evidenciam com segurança que o réu possuía arma de fogo e munições de uso permitido com numeração suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, conforme se vê pelo laudo pericial (fls. 26/29), o revólver Taurus calibre nominal .38 Special (.38 Longo), no estado em que se encontrava, se mostrou apto à realização de disparos.

Inclusive, “O teste de recenticidade de disparo, pela técnica de reações químicas por IPT em meio amoniacal, levado a efeito na referida arma, resultou positivo para disparo recente” (fls. 28).

Constou, ainda, no referido laudo, que a numeração da arma se encontrava totalmente suprimida, de modo que, ante todo o acervo probatório, que se mostrou uníssono e coeso, o caso se amolda ao delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei Federal n. 10.826/03.

Ressalto que o laudo foi elaborado de maneira clara e discriminada por órgão especializado, sendo que nada há que o inquine descrédito.

Esclareço que os delitos previstos na supracitada lei são crimes de perigo abstrato, isto é, representam afronta à norma jurídica que visa, neste caso, garantir e preservar a segurança coletiva, conforme já decidiu o STF (HC 96.072) e o STJ (HC 156.736).

Assim, a situação de perigo é presumida, independentemente da intenção do agente, de forma que a consumação se dá com a mera posse da arma de fogo, sem o registro e o necessário porte, sendo irrelevante a sua efetiva utilização – apesar do teste positivo para disparo recente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Porte de arma de uso permitido. Defesa alega, em preliminar, atipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado. No mérito, pede a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a consideração da atenuante da confissão na segunda etapa de dosimetria, diminuindo-

se as penas. Almeja, por fim, a restituição da arma apreendida e da fiança depositada. Sentença comporta parcial reforma. Preliminar rejeitada. Crime de perigo abstrato. Precedentes dos Tribunais Superiores. Ausência de comprovação do alegado prejuízo. No mérito, autoria e materialidade demonstradas. Réu foi preso em flagrante e admitiu a prática delitiva. Laudo pericial comprova a potencialidade lesiva da arma e das munições apreendidas. Condenação de rigor. Dosimetria comporta ligeiro reparo. Na segunda fase, necessário reconhecer a confissão. Penas inalteradas, pois resta impossível operar a redução aquém do mínimo legal nesta fase. Súmula 231 do STJ. Regime inicial aberto mantido. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Mantido efeito extrapenal da condenação, nos termos do artigo 91, inciso II, a, do Código Penal. Juízo a quo já determinou a restituição da fiança. Recurso parcialmente provido, sem alteração nas penas. (TJSP; Apelação Criminal 0004814-03.2017.8.26.0635; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019)

Portanto, a conduta do réu foi suficiente para ensejar a tipificação do delito, de modo que, comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação pela infração ao delito do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei Federal n. 10.826/03 é medida que se impõe.

II) Do crime previsto no artigo 12 da Lei Federal n. 10.826/03:

A materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido foi evidenciada boletim de ocorrência n. 114/2021 (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), pelo BO/PM n. 202102201201709 com fotografias da arma e munições (fls. 12/25), pelos laudos periciais (fls. 34/37 e 38/41), pelo relatório final (fls. 50/51), pelos elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, bem como pela prova oral colhida em juízo.

De igual modo, a autoria também foi demonstrada.

Inexiste discussão acerca do fato de que a arma de fogo e munições foram apreendidas na barbearia e na casa do réu.

Além da confissão do réu, os depoimentos dos policiais foram uníssomos e evidenciam com segurança que o réu possuía arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, entendo que a conduta do acusado se enquadra perfeitamente no tipo penal do artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/03.

No mais, é importante frisar que, conforme atestaram os laudos periciais (fls. 34/37 e 38/41), o revólver Taurus calibre nominal .38 Special (.38 Longo), de número de série 376541, bem como as munições, ofereciam condição de serem utilizadas para disparo.

Ademais, o laudo foi elaborado de maneira clara e discriminada por órgão especializado, sendo que nada há que o inquine descrédito.

Como dito, os delitos previstos na Lei Federal n. 10.826/03 são crimes de perigo abstrato, isto é, representam afronta à norma jurídica que visa, neste caso, garantir e preservar a segurança coletiva.

Assim, a situação de perigo é presumida, independentemente da intenção do agente, de forma que a consumação se dá com a mera posse da arma e da munição, sem o registro e o necessário porte, sendo irrelevante a sua efetiva utilização.

Portanto, a conduta do réu foi suficiente para ensejar a tipificação do delito, de modo que, comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação pela infração ao disposto no artigo 12 da Lei Federal n. 10.826/03 é medida que se impõe.

III) Do concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal)

Comprovadas a materialidade e autoria em relação aos delitos previstos nos artigos 12 e 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03, necessário estabelecer os critérios de cálculo da pena.

Registro ser clássico caso de concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal, conforme jurisprudência pacífica do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE

CRIME ÚNICO. VÁRIAS ARMAS. IMPUTAÇÕES DIVERSAS: ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/1993. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. 1. Há precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais de uma arma, munição, acessório ou explosivo com o mesmo agente não caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado. 2. Na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio, pois, no caso, a conduta praticada pelo agravante se amolda a tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso. 3. Tem-se reconhecido a existência de crime único quando são apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido. Sucede que referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013). 4. O STJ firmou entendimento de que é possível a unicidade de crimes, quando, no porte ilegal, há pluralidade de armas, equacionando-se a reprimenda na fixação da pena-base. Na espécie, contudo, a pretensão não se justifica, dado se buscar o reconhecimento de crime único diante de imputações distintas: arts. 14 e 16, párr. único, da Lei 10.826/03 (HC n. 130.797/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/2/2013). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no Resp 1547489/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016)

DOSIMETRIA. APREENSÃO DE MUNIÇÕES DE DIFERENTES CALIBRES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. APLICAÇÃO DA PENA RELATIVA AO CRIME MAIS GRAVE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Este Sodalício já se pronunciou no sentido de que a apreensão de armas ou munições de uso permitido e de uso restrito, no mesmo contexto fático, implica na caracterização de crime único por atingir apenas um bem jurídico, devendo ser aplicada somente a pena do crime mais grave. 2. Mais recentemente, porém, esta Corte Superior de Justiça vem entendendo que os tipos penais dos arts. 12 e 16, da Lei n. 10.826/03, tutelam bens jurídicos diversos e que, por tal razão, deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático. 3. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a tese aplicada pelo juízo primevo, no sentido de que estaria caracterizado o crime único, tendo em vista que o apelo foi exclusivo da defesa, porém não deixou de observar, de maneira acertada, que o acusado foi beneficiado quanto à questão e que não seria cabível o pedido de aplicação da pena mais branda. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1122758/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018).

Assim, o caso atrai a aplicação do concurso formal de crimes entre artigos 12 e 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03, devendo a pena mais grave ser aumentada de 1/6 até 1/2 quando da dosimetria da pena.

Portanto, passo à dosimetria da pena do crime previsto, com base no critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

I) Artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei Federal n. 10.826/03:

O artigo 16, §1º, da Lei Federal n. 10.826/03, remete à pena-base do caput, que tem como base o patamar de 03 (três) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. O acusado não ostenta maus antecedentes (fls. 118/119 e 120). Inexistem nos autos elementos indicativos quanto à personalidade e conduta social do réu. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são normais à espécie. Por fim, nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, fixo a pena-base, no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Presente, contudo, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, que, entretanto, não tem relevância, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, não verifico a ocorrência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

II) Artigo 12 da Lei Federal n. 10.826/03:

O artigo 12, caput, da Lei Federal n. 10.826/03, tem como pena base o patamar de 01 (um) ano de detenção e multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. O acusado não ostenta maus antecedentes (fls. 118/119 e 120). Inexistem nos autos elementos indicativos quanto à personalidade e conduta social do réu. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são normais à espécie. Por fim, nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, fixo a pena-base, no mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Presente, contudo, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, que, entretanto, não tem relevância, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, não verifico a ocorrência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

III) Concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal):

Como já exposto, os delitos cometidos em violação aos artigos 12 e 16, §1º, inciso IV, da Lei Federal n. 10.826/03 foram cometidos em concurso formal, razão pela qual, nos termos artigo 70 do Código Penal, aplico a pena mais grave dentre elas, aumentada de 1/6, resultando na pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 dias-multa.

Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, caput, ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato. O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o aberto, nos moldes do estabelecido pelo art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, já que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e de detenção, inexistindo circunstâncias judiciais que evidenciem necessidade de tratamento mais rigoroso. Diante da quantidade de pena aplicada e da presença dos demais requisitos subjetivos e objetivos, cabível a substituição de pena prevista nos artigos 44 e seguintes do Código Penal. Assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos: (i) uma de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser prestada em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução e (ii) outra de prestação pecuniária no patamar de um salário mínimo, atualmente R\$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), a ser depositada na conta judicial vinculada à 2ª Vara da Comarca de Igarapava (conta judicial n. 1100112752843), na forma da Resolução nº 154/12 do CNJ e Provimento CG nº 32/2013 do TJ-SP, administrada por este Juízo.

A prestação pecuniária deverá ser paga em até 08 (oito) parcelas iguais, sucessivas e mensais, iniciando-se no prazo fixado pelo Juízo da Execução. Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da pena, eis que substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu OBEADIO VIANA pela prática dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida (previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei Federal n. 10.826/03) e posse de arma de fogo e munições de uso permitido (previsto no artigo 14, da Lei Federal n. 10.826/03) à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de e 11 (onze) dias-multa, fixadas no patamar mínimo legal.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos: (i) uma de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser prestada em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução e (ii) outra de prestação pecuniária no patamar de um salário mínimo,

atualmente R\$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), a ser depositada na conta judicial vinculada à 2ª Vara da Comarca de Igarapava (conta judicial n. 1100112752843), na forma da Resolução nº 154/12 do CNJ e Provimento CG nº 32/2013 do TJ-SP, administrada por este Juízo. A prestação pecuniária deverá ser paga em até 08 (oito) parcelas iguais, sucessivas e mensais, iniciando-se no prazo fixado pelo Juízo da Execução.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há fundamentos para sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), motivos pelos quais poderá recorrer em liberdade.

Quanto à arma e munições, ficam liberadas, independentemente do trânsito em julgado para as partes, para doação ou destruição, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/2003 e § 3º do art. 509 das Normas de Serviço da CGJ do TJSP.

Transitada em julgado essa sentença: a) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) Notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP).

Desnecessária a inclusão do nome do condenado no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Cumpridas as formalidades legais, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 23 de setembro de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)